

1500126-60.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O DA ESPECIALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500126-60.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500126-60.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020213/2022 - 02º D.P. AMERICANA, 22591492 - 02º D.P. AMERICANA, 140/22/345 - 02º D.P. AMERICANA, 2020213 - 02º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL NOGUEIRA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

MICHEL NOGUEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, no período noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, um televisor da marca "SONY", um mouse sem fio da marca "POSITIVO", sete lençóis impermeáveis da marca "INOVA", e oito protetores de colchões da marca "BAMBU CARE", além de um óculos de grau e um fio de extensão, tudo pertencente ao estabelecimento comercial "PROHOUSE COLCHÕES".

A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022 (fls. 117/119).

O réu foi citado, apresentando defesa (fls. 157/162).

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima e as testemunhas arroladas, bem como o réu foi interrogado (fls. 186/187).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 217/220), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto qualificado.

A Doutora Defensora requereu o reconhecimento da dependência química (fls. 226/230).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, reitera-se o já deliberado as fls. 173/178, ou seja, não se verifica qualquer nulidade, tendo em vista que a instauração do incidente de insanidade, ante a dependência toxicológica, pode ser efetuado a qualquer tempo do processo. Há que se analisar que não consta qualquer solicitação da defesa para tanto.

Segundo HÉLIO TORNAGUI, o verbo ordenará, empregado no artigo 149 do Código de Processo Penal não pode levar o intérprete a concluir que o juiz tem a obrigação de atender sempre ao requerimento de exame pericial. Lembra o ilustre penalista que o artigo 184 do mesmo diploma legal que, com exceção do exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a realização de perícia:

"... quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Se o juiz verifica que o pedido é meramente protelatório ou tumultuário, cabe-lhe policiar o processo e negar a perícia. Do contrário, não seria um requerimento, mas uma imposição... Seria uma incoerência que o juiz pudesse repelir o laudo (CPP, art. 182) e não pudesse negar o exame" ("Curso de Processo Penal", Saraiva, 1980, p. 254).

Segundo Vicente Grecco Filho:

"... a dependência para consubstanciar a base biológica da inimputabilidade deve ser objetivamente diagnosticada como doença mental, isto é, psicopatia ou enfermidade da mente, de fundo físico ou psíquico ou ambos ("Tóxicos", Saraiva, 4ª ed., 1984, pág. 131).

No mais, conforme se verifica pelo interrogatório judicial (termo de audiência as fls. 186/187), o réu, em juízo respondeu com firmeza, clareza e coerência as perguntas que lhe foram feitas, demonstrando que estava bem orientado, sem qualquer perturbação da mente, ou da vontade.

Só se justificaria o exame de dependência se o juiz suspeitasse ser o réu dependente de drogas, que revelasse características próprias de quem está com a saúde mental perturbada, o que não é o caso dos autos.

Em suma, tal exame só é determinado quando, em concreto, for reputado necessário pelo julgador, qualquer que seja o crime cometido, não caracterizando o seu indeferimento cerceamento de defesa. Nesse sentido, o entendimento dos nossos tribunais:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ESTUPRO. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA NÃO REALIZADO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. Quanto à nulidade do processo, conforme o reconhecido na manifestação ministerial, importa reconhecer que "a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do

paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017), sendo incompatível com a via do habeas corpus analisar as razões fáticas que motivaram o julgador a indeferir o incidente" (AgRg no HC 484.526/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019). 3. (...). 5. Writ não conhecido. (HC 521.458/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O DA ESPECIALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016). 3. No caso, o pleito formulado pela defesa, com relação ao exame de dependência toxicológica, foi motivadamente indeferido, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica. 4. "A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado" (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016). 5. (...). (HC 446.698/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - INDEFERIMENTO MOTIVADO - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PLEITO PREJUDICADO. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica quando não houver indício de nenhuma perturbação que interfira na capacidade de entendimento da ilicitude da conduta e na autodeterminação. Caracterizam-se os maus antecedentes quando o trânsito em julgado for posterior, mas o crime for praticado anteriormente ao em análise. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas. Resta prejudicado o pleito de isenção das custas processuais diante do deferimento da benesse na sentença. (TJMG - Apelação Criminal 1.0261.15.008308-5/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/01/2020, publicação da súmula em 29/01/2020)

ENTORPECENTE - Exame de dependência toxicológica - Desnecessidade quando não demonstrada a existência de deficiências mentais - Declaração de voto parcialmente vencido (TJSP) RT 728/534

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tráfico de entorpecente - Exame de dependência do acusado à droga - Indeferimento - Magistrado que o entendeu desnecessário, diante da conduta daquele no processo - Nulidade pretendida - Inexistência - Recurso de "habeas corpus" não provido - Inteligência do art. 22, § 5º, da Lei 6.368/76 (STF - Ement.) RT 546/450

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Inexistência - Exame de dependência ao tóxico - Não realização do pleiteado por acusado de tráfico de entorpecente - Ausência de prova, sequer de receita médica, a justificá-lo - Paciente que se apresenta em juízo em aparente condição de normalidade psicossomática - "Habeas corpus" denegado (Ement.) RT 565/311

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 06/08, 09, 52/55 e 103/106, e laudo de fls. 192/200.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, o réu estava na posse do bem subtraído.

A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor

- validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

O representante da vítima, ouvido em Juízo, informou que não estava na loja, sendo que, por volta das 6 horas da manhã, foi informado pelo supervisor acerca do furto. Narrou que dirigiu-se até a loja, onde constatou a subtração, e dano na trava da porta da frente, retirando-a do trilho. Disse, ainda, que quase todos os bens foram recuperados pela polícia, sendo que a televisão foi danificada.

Não há nos autos prova de que a vítima conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e terminaram por deter o réu.

Os policiais militares esclareceram que foram informados de um possível furto em andamento, e dirigiram-se até o local. Disseram, ainda, que nas proximidades visualizaram dois indivíduos, sendo que o réu carregava uma televisão e o outro indivíduo carregava uma sacola contendo as fronhas de colchão. Efetuaram a abordagem no réu, sendo que o segundo indivíduo conseguiu evadir-se. Indagado, o réu confirmou a prática do delito. Narraram que dirigiram-se a loja, onde verificaram que a porta estava apenas encostada, com a fechadura forçada. Por fim, o réu não aparentava estar sob o efeito de substância entorpecente, e alegou ser usuário de drogas.

O réu, ouvido em Juízo, confirmou a prática do furto. Declarou que estava apenas com a televisão. Narrou que estavam usando drogas, e o outro indivíduo, um menor, indicou que sabia de um lugar para furtarem, e foi com ele. Disse que o menor indicou para o depoente pegar a televisão, enquanto ele pegava as outras coisas. Por fim, pouco após saírem da loja, foi abordado pela polícia.

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, inclusive acerca das qualificadoras.

Ainda, a qualificadora de rompimento de obstáculo encontra-se demonstrada pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 192/200, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

Com efeito, a prova nos autos demonstra que o réu, utilizando-se da menor vigilância, durante o período noturno, mediante o rompimento de obstáculo, ou seja, a porta, subtraiu os objetos indicados na denúncia.

Além desses indícios, existe outro forte indício, que é a pretérita condenação do réu pela prática de crimes contra o patrimônio o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

PROVA - Maus antecedentes - Valor: 30(d) - Os antecedentes negativos não servem de base exclusiva para decreto condenatório mas constituem importante adinículo para a formação do convencimento. (Apelação nº 1.171.909/6, Julgado em 03/02/2.000, 7ª Câmara, Relator: Corrêa de Moraes, RJTACRIM 47/133)

A respeito da prova indiciária, nesse sentido é o entendimento da doutrina: "A prova da autoria não se faz apenas por confissão espontânea ou por declaração das testemunhas, mas, muitas vezes, com base em prova meramente indiciária. Constitui erro crasso, como diz Mestre Frederico Marques, citando Vito Gianturco, o afirmar-se de que nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará lugar à condenação, pois tal assertiva equivaleria a abolir-se a prova indiciária do processo penal (MARTINS, Weber "O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal - Forense - Rio de Janeiro - 1995 - p. 459).

Como já entendido por nossos Tribunais:

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL - CONDENAÇÃO VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Existindo provas indiciária e circunstancial concludentes, no que tange a existência da consciência da origem espúria do bem pelo agente, circunstâncias essas aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa inculpação, impossível de se cogitar a absolvição. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000710-58.2011.8.26.0091; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª. Vara Judicial; Data do

Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

“O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do Código de Processo Penal” (Ap.1070845/5, Rel. Renato Nalini, j. 06.10.1997, rolo 1132, flash 0194, fls.09).

PROVA - Presença de indícios concatenados - Ausência de prova direta que os desautorize - Validade - Entendimento:61 - Sendo a prova indireta mas segura, formada por indícios concatenados, sem contra-indícios ou prova direta que os desautorize, possível é a condenação nela baseada, mormente se a materialidade do delito é inconteste. RJDTACRIM VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 133 RELATOR: - MARREY NETO

PROVA - Furto - Presença de indícios - Valor:182 - Sendo os crimes de furto praticados normalmente sem a presença de testemunhas, os indícios passam a ter valor relevante para a apuração da autoria. RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 324 RELATOR: - MESQUITA DE PAULA

Verifica-se, também, que não há que falar-se em inimputabilidade em razão de consumo de substância entorpecente e/ou álcool. Primeiro, porque não comprovada. Segundo, porque a ingestão de bebida alcoólica, ou droga, só é excludente de culpabilidade se oriunda de fato culposos ou de força maior. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

DANO QUALIFICADO, DESACATO E LESÃO CORPORAL LEVE CIRCUNSTANCIADA, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE, COM REDUÇÃO DAS PENAS. Materialidade e autoria dos delitos bem demonstradas nos autos (...). SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL. Não há que se falar em inimputabilidade ou em semi-imputabilidade da apelante, pois tanto o artigo 28, §§ 1º e 2º, do Código Penal, como os artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, exigem, para a isenção ou redução da pena, que a embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, e a dependência ou o efeito de droga, sejam provenientes de caso fortuito ou força maior, e que o agente, em razão da embriaguez, dependência ou efeito de drogas, seja, ao tempo da ação ou omissão, inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já a embriaguez, voluntária ou culposa, como no presente caso, não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, inciso II). Adoção legislativa da actio libera in causa, de modo que, se o agente deu causa à embriaguez voluntária (o agente quis se embriagar) ou culposamente (o agente não queria embriagar-se, mas por imprudência chega àquele estado), ele responde pelos atos praticados em estado de ebriedade. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500190-16.2019.8.26.0585; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização de exame de dependência químico-toxicológica. Inocorrência. Ato justificadamente indeferido pelo magistrado no exercício de seu livre convencimento motivado - Mérito Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Condenação mantida. Pleito de isenção de pena, com encaminhamento a tratamento adequado à dependência química, nos termos do art. 45, da Lei n.º 11.343/06. Descabimento. Dispositivo legal que exige comprovação da inimputabilidade ou prática do delito sob efeito de drogas em razão de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos, não bastando a mera alegação de dependência química. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0001976-42.2009.8.26.0288; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2014;

Data de Registro: 03/11/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Recurso defensivo - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Reconhecimento efetivado pela vítima e confissão parcial dos acusados que, aliados aos demais elementos de convicção, dão a certeza do cometimento do delito - Inimputabilidade que não restou comprovada - Eventual atuação delitiva sob efeito ou dependência de droga que não decorreu de caso fortuito ou força maior - Condenação mantida - (...). (TJSP; Apelação Criminal 0053723-90.2014.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2016; Data de Registro: 09/06/2016)

Por fim, a consumação ocorreu em razão do bem ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, pouco importando a recuperação posterior. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução) 3. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau. (Resp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 58/76) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. No mais, em se tratando de furto qualificado (rompimento de obstáculo), há maior reprovabilidade da conduta do acusado, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal. Exaspero, por isso, a pena base em 1/6 (um sexto), delimitando-a em dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA



JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 58/76. Contudo, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ)

Ainda, por força do que dispõe o § 1º, do artigo 155, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento do repouso noturno, ao furto qualificado acresço a pena em 1/3 (um terço), perfazendo em 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1721890/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA FIGURA TÍPICA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DO DELITO QUALIFICADO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). III - Pedido de exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno. O entendimento consagrado neste eg. Superior Tribunal de Justiça é de que não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. A jurisprudência deste eg. Tribunal Superior é firme no sentido de que as normas que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4º do art. 155 do Código Penal) como na referida causa de aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor do resultado. Impende registrar que a causa de aumento de pena em comento, assim como as demais majorantes previstas no Código Penal e na legislação esparsa, nada mais são do que circunstâncias especiais erigidas pelo legislador infraconstitucional como de maior gravidade. Nesse contexto, a inserção na derradeira etapa da dosimetria apenas serve para cristalizar a maior reprovação da conduta, tendo em mente a existência de um procedimento sancionatório lógico, gradativo e escalonado. Precedentes: STJ e STF. IV - (...). Habeas corpus não conhecido. (HC 509.594/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

À míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado em razão de ser o réu reincidente específico, além do fato de que conta com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA FIGURA TÍPICA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.

COMPATIBILIDADE DO DELITO QUALIFICADO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). IV - Com efeito, "é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo" (HC n. 452.147/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/08/2018). Na hipótese em foco, nota-se o delineamento de elementos concretos para a imposição de regime mais gravoso - os maus antecedentes, a reincidência e outras duas condenações definitivas a indicar a reiteração delitiva -, não se restringido a fundamentação a considerações vagas e genéricas relativas à gravidade abstrata do crime. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.594/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

O réu não poderá apelar em liberdade, por ser reincidente. Além disso, o réu encontra-se preso por força de prisão em flagrante delito, o que demonstra que sua custódia é necessária para a garantia da ordem pública.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu MICHEL NOGUEIRA DE SOUZA à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.  
P. I. C.

Americana, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA